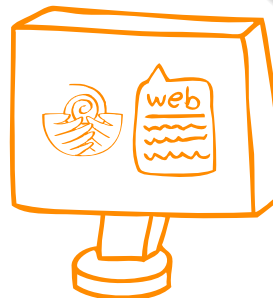




DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



Curso Software

Texto guía





Unidad I

El software y su protección en el derecho de autor

2

Resultados del aprendizaje



Una vez realizadas las lecturas y ejercicios correspondientes a la Unidad I, el estudiante estará en capacidad de:

- Indicar qué protege el derecho de autor en la industria del software.
- Diferenciar la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual en el software.
- Distinguir los tipos de derechos que existen para los creadores en la industria del software.

Conocer las particularidades del trámite del registro de soporte lógico ante la DNDA.





Es indudable que el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) durante las últimas décadas ha incrementado el peso de la industria del *software* en el crecimiento, bienestar y promoción de las naciones. El avance de las TIC y el crecimiento de la industria del *software*, han significado el surgimiento de nuevos e interesantes retos para el mundo de la propiedad intelectual, y en particular para la protección del derecho de autor y derechos conexos en los entornos digitales. Es por ello que, a lo largo del curso se revisarán las principales controversias en materia de protección del *software* y se aclararán los alcances, limitaciones y excepciones del derecho de autor en lo que atañe a la producción de *software*.

El *software* es el lenguaje mediante el cual los computadores suelen ser programados; es decir, son el conjunto de instrucciones diseñadas particularmente para el funcionamiento de los computadores. Un concepto cercano que generalmente produce confusión en los usuarios es el *hardware*, el cual hace referencia exclusivamente a la variedad de objetos físicos¹ (memorias RAM, discos duros, teclados, pantalla, etc.), que son usados como componentes de los computadores. De esta manera, herramientas informáticas tan conocidas a nivel mundial como *Microsoft Office*, *Windows*, *Internet Explorer*, *Adobe Acrobat*, *Google Chrome* o *Mozilla* constituyen esencialmente programas o *software* que son leídos a través de los diferentes dispositivos electrónicos como el computador personal, el *Ipad*, el *Smart Phone*, entre otros.

Gracias a la multiplicidad de elementos que componen la definición de *software*, así como una suerte de vacío institucional de lado de los principales convenios y tratados internacionales en materia de derecho de autor (principalmente el Convenio de Berna²), se ha generado un debate álgido en torno a la forma de protección del *software*. La posición de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, respaldada por una gran parte de los países que las conforman y con base en la concepción del *software* como bien particular, se orienta a protegerlo a través del derecho de autor en la categoría de obras literarias y artísticas, el cual fue incluido mediante los Acuerdos sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) en 1994 y el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996³.

Nuestro país incorporó el concepto de *software* dentro de su legislación interna a través de la adaptación de la norma de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) relativa a derecho de autor y derechos conexos - Decisión Andina Número 351 de 1993, que lo definió como la

*(...) expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador, -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso*⁴.

¹ Universidad de Jaén, V. d. (2010). Universidad de Jaén, Vicerrectorado de Investigación. Disponible en: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf. Consultado el 18 de enero de 2016.

² RÍOS, Wilson Rafael. La Propiedad Intelectual en la Era de las Nuevas Tecnologías. Pg. 253. Universidad de los Andes. 2009.

³ Artículo 10 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) de 1996.

⁴ Artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".



En consecuencia, esa misma Decisión incluyó al software dentro de las categorías de obras protegidas por el derecho de autor y estableció que los programas de ordenador deben protegerse bajo los mismos parámetros de las obras literarias.⁵ Este amparo debe extenderse tanto a los derechos morales como a los derechos patrimoniales.⁶ De igual manera, a través del Decreto 1360 de 1989 se incluyó al software dentro de las categorías de obras susceptibles de ser registradas en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

Es de anotar que al igual que diversos países alrededor del mundo como Estados Unidos, Hungría, Australia, India, Alemania, Francia, y Reino Unido, entre otros, incorporaron en su legislación de derecho de autor, la protección para el software⁷, Colombia y los países de la Comunidad Andina reconocieron dicha protección antes de la expedición de los acuerdos y tratados internacionales mencionados anteriormente.

El derecho de autor y el software: ¿Qué se protege?

El derecho de autor protege los programas de ordenador o el software, independientemente de la forma como éstos se expresan. Para la creación de un software se requiere indispensablemente de un código fuente y de un código objeto. El primero es aquel lenguaje que puede ser percibido por los seres humanos. Su objetivo es permitirle al creador del programa de ordenador determinar de manera clara el objeto de su creación y hacer las correspondientes anotaciones sobre la manera adecuada para usar el programa⁸. Es así que cada programador le imprime su estilo único y particular así como la forma de utilizar el respectivo lenguaje de programación⁹ sobre el cual se escribe el formato. Por medio del código fuente se le proporcionan a la computadora una serie de instrucciones que ésta, mediante un proceso interno, las redacta y organiza configurándose el software en código fuente¹⁰. En ese sentido, el carácter escrito de las instrucciones en que se expresan los programas es el respaldo de la protección del software como una obra literaria¹¹.

4

Por el contrario, el código objeto es el proceso mediante el cual la máquina convierte y decodifica esas órdenes, expresadas mediante un lenguaje binario conformado por ceros y unos y que sólo puede ser leído por los computadores o las máquinas, pero no por las personas. Generalmente el software que es comercializado se presenta en manera de código objeto soportado en medios como los CD o discos ópticos o medios completamente digitales a través de las ventas de software en línea en Internet (caso de los antivirus). Por estos motivos el derecho de autor protege el software tanto en lo que se refiere al código fuente como al código objeto¹².

Es necesario mencionar el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996, dado que establece que los programas informáticos están protegidos como obras literarias en el marco de

⁵ Artículos 4 y 23 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".

⁶ MARÍN, Hugo. *Apuntes Generales sobre los Derechos Intelectuales*, pg. 40. Impresores Marín Martínez. Ltda. 1997.

⁷ VASQUEZ, Víctor. *International IP Protection of Software. History, Purpose and Challenges*. WIPO. 2007. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_ip_cm_07/wipo_ip_cm_07_wwww_82573.pdf. Consultado el 19 de enero de 2016.

⁸ CHARRIA, Fernando. *derecho de autor en Colombia*. Pg. 82. Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali- Colombia. 2001.

⁹ El lenguaje de programación es Lenguajes Informáticos como Oracle, Basic, Java, Fortran, etc..

¹⁰ MAYORGA, Jaime. *Propiedad Intelectual Sobre Software, Circuitos Integrados y Transmisión Electrónica de documentos*. Manual sobre la Propiedad Intelectual de productos Derivados de la Actividad Académica en Universidades y Centros de Investigación. Pg. 53. Universidad Nacional de Colombia. Colciencias. 1997.

¹¹ GUADAMUZ, Andrés. *Patentabilidad del Software, Nuevas Cuestiones Jurídicas*. 2008. Disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html. Consultado el 19 de enero de 2016.

¹² Artículo 23 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".





lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. De la misma forma la normativa andina extiende el concepto de software tanto a la documentación técnica como a sus manuales de uso¹³

Tipos de derechos: derechos morales y derechos patrimoniales

Los creadores originales de obras protegidas por el derecho de autor, entre las que se encuentra el software, sus causahabientes y los titulares de derechos gozan de una serie de prerrogativas del orden moral y pecuniario según corresponda, las cuales les son otorgadas por la ley. El derecho de autor clasifica dichos privilegios en derechos morales y derechos patrimoniales, con las siguientes características:

Derechos morales

Los derechos morales son aquellos que no tienen un contenido económico (derechos personales), los cuales recaen sobre la obra y su relación de carácter intrínseco con el autor. En virtud de estos derechos se reconoce la autoría de la obra, dado que es el producto y resultado del ingenio y la creatividad de su autor, los cuales no se pueden desconocer, debido principalmente a que existe un vínculo inequívoco e inalienable entre los dos. El autor no puede existir sin su obra, ni la obra sin su autor. Además, por ser la obra producto y creación de su autor, los derechos morales son intransferibles, inembargables e irrenunciables y no tienen limitación en el tiempo¹⁴. Estos derechos están contemplados en la normativa¹⁵ y son:

5

Derecho del inédito. Facultad del autor de decidir si publica, divulga o no su obra, tenerla en su ambiente privado o comunicarla al público y en qué forma lo hará.

Derecho de paternidad. Derecho que tiene el autor para que se le reconozca la autoría sobre su obra en todo momento, es decir, se reivindique la autoría sobre la obra en todo acto en el que se utilice la obra. El autor puede ser nombrado a través de su nombre o de su seudónimo¹⁶.

Derecho de integridad. Es la facultad de impedir cualquier deformación de la obra que pueda perjudicar el honor y reputación del autor. Puede presentarse el caso en que un software encargado por una compañía para el registro, sea modificado y utilizado para espiar a los trabajadores, lo cual puede eventualmente lesionar la reputación de su autor.

Derecho de arrepentimiento. Es la potestad que tiene el autor para retractarse de la publicación de su obra, permitiéndole en cualquier momento poder removerla de los espacios

¹³ Artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".

¹⁴ LIPSYC, Delia. Derecho de autor y Derechos conexos. Argentina: UNESCO - CERLALC - ZAVALIA, 2006. 92-9057-047-4.

¹⁵ Artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos" y artículo 30 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

¹⁶ OLARTE, Jorge Mario. ROJAS, Miguel. Manual de derecho de autor para Alcaldías y Gobernaciones. Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2011.





de circulación. El autor debe indemnizar a las personas que resultaren afectadas con esta actuación¹⁷.

Derecho de modificación. Es el derecho que tiene el autor para que ejecute los cambios y reformas que este considere necesarias con respecto a su obra. Este derecho lo puede ejercer el autor tanto antes como después de la publicación de la obra. Al igual que en el derecho de arrepentimiento el autor debe indemnizar a los terceros afectados con dicha determinación.

Derechos patrimoniales

Los derechos patrimoniales o “de explotación” representan el derecho del autor de beneficiarse económicamente de su producción intelectual. Estos derechos, al contrario de los morales pueden ser transferidos, ya sea mediante venta, donación, contrato u otras formas que se verán más adelante, además de estar limitados, incluso temporalmente. En resumen, estos derechos permiten al autor la autorización y prohibición de las obras respecto de cualquier tipo de utilización que esta pueda llegar a tener. Estos derechos son los siguientes¹⁸:

Derecho a reproducir la obra. Una obra puede ser reproducida una vez está fijada en algún soporte, de lo contrario se infringe el derecho de reproducción. La obra se reproduce cuando se realizan copias de la misma ya sea de manera total o parcial y por cualquier medio. Algunos ejemplos de infracciones o desconocimiento del derecho de reproducción son: Realizar una copia de un programa de ordenador sin la debida autorización del titular y sin estar amparado por la excepción de la copia de seguridad. Igualmente, cuando se alojan copias en el disco duro de un computador producto de la descarga de software en un sitio web, en principio, se está haciendo un acto de reproducción de la obra.

Derecho a la distribución. Es el derecho que tiene el autor de autorizar o prohibir la venta, el alquiler o el arrendamiento de la obra. En el caso del software encontramos que los titulares del derecho autorizan a ciertas cadenas comerciales para la distribución legal de los programas de ordenador, ese es el caso, del alquiler de video-juegos que se realizaba en las tiendas de Blockbuster, modelo de negocio que ha desaparecido con el tiempo, para dar paso a otros modelos de negocio en Internet. Sin embargo, es importante aclarar que para nuestra legislación, si se ofrece la obra a través de portales internet, fijada en soportes tangibles como es el caso de los CDs, estamos en presencia de un acto de distribución, pero si lo que se ofrece es la obra en formatos digitales, estamos en presencia de un acto de puesta a disposición como lo explicaremos más adelante. . De otro lado, existen lugares donde se comercializa el software en soportes tangibles, sin autorización de sus titulares, infringiendo las normas de derecho de autor, particularmente en lo referido al derecho de distribución.

Derecho a la comunicación pública. El software puede ser comunicado¹⁹ o difundido al público por cualquier medio o procedimiento (alámbricos o inalámbricos); en este sentido, el

¹⁷ Parágrafo 4 del artículo 30 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.

¹⁸ Artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos” y artículos 3 y 12 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.

¹⁹ Literal c del artículo 12 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.



derecho de comunicación pública abarca todos los actos por los cuales una cantidad indeterminada de personas puedan tener acceso a la obra sin que ésta haya sido distribuida mediante previa distribución de ejemplares.

Derecho de puesta a disposición. Este derecho es una forma de comunicación pública por medio de la cual las personas en general tienen acceso a la obra desde el lugar y el momento que cada uno elija. Un claro ejemplo de esto puede ser el de aquellas páginas de Internet que ponen a disposición de sus usuarios programas de ordenador para que los usuarios puedan descargarlos e instalarlos en sus dispositivos para utilizarlos. . Para realizar este tipo de actividades, es necesario contar siempre con la autorización de los titulares del derecho. Igualmente, existe un gran número de páginas de Internet que ofrecen distintos tipos de software y aplicaciones, como la página de la compañía Apple, a través de la cual los usuarios pueden descargar aplicaciones. Para nuestra legislación esto es un acto de puesta a disposición del público, porque los actos de distribución solo se realizan frente a obras fijadas en soportes tangibles como fue explicado anteriormente.

Derecho a la transformación de la obra. Una obra se puede transformar adaptar, traducir, o arreglar²⁰. El titular puede autorizar estos actos o ceder el derecho, a cambio de una remuneración equitativa. Las traducciones son actos de transformación a la obra, una adaptación de obras preexistentes en la medida en que cambian su idioma o lenguaje original a otro; como el trabajo del traductor autorizado es también creativo, y en cierta medida original, se protege la traducción realizada con la obligación de citar siempre al autor y el título de la obra original traducida.

Titularidad de los derechos, obras colectivas y en colaboración y duración de la protección

Titularidad de los derechos

Titular originario. El autor es la persona física que crea la obra, pues el hombre, en sentido amplio, es el único capaz por sí mismo de realizar un proceso creativo que lleve a la consecución de la obra. Así, Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra²¹. En este sentido el titular originario es el conjunto de personas naturales que ejecutan la labor intelectual tendiente a la realización de una obra artística o literaria²². La protección del derecho de autor opera desde el momento mismo de la creación de la obra. Esta protección se refiere tanto a las prerrogativas de carácter patrimonial como moral²³. En materia de software esta protección se realiza desde la creación del programa en cualquiera de sus formatos ya sea código fuente o código objeto, como se anotó anteriormente.

²⁰ Literal b del artículo 12 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

²¹ Artículo 10 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".

²² Artículo 3 de la Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".

²³ Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor 2010/2-2010-4233.





Titular derivado. Ahora bien, con el término titularidad se hace mención de la persona que ejerce los derechos sobre una obra, una persona natural o jurídica distinta del autor. Sin embargo, la titularidad originaria recae únicamente sobre el autor. Este, a su vez, puede transferir todos o algunos de sus derechos patrimoniales sobre la obra a un tercero con identidad de persona natural o jurídica. Esta persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar entonces la titularidad derivada de los derechos patrimoniales sobre la obra.²⁴. Es importante recalcar que una persona jurídica nunca será un titular originario de la obra, su titularidad siempre se considerará derivada, pues como ya dijimos, el titular originario en todas las ocasiones es el autor.

Obras colectivas y en colaboración

En Colombia se define una obra en colaboración como la producida conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados por ser la obra indivisible, por lo cual la titularidad pertenece en común a todos los coautores²⁵. No se consideran obras en colaboración aquellas en las que no existe un trabajo mancomunado entre los autores para alcanzar una propuesta común. Un ejemplo de las obras en colaboración, lo constituyen los llamados Proyectos Independientes o “Indie”, donde se reúnen diversas personas naturales con poco presupuesto para la realización de un videojuego, el cual posee aportes de cada uno de los creadores, siendo imposible separarlos, puesto que integrados forman un determinado software.

Particularmente, se reconoce una obra colectiva como la producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre²⁶. Se establece que el titular del derecho de autor será el editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizan los aportes de las personas naturales que contribuyen en las obras colectivas creadas dentro de un contrato laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte individual de cada participante. Estas obras se presentan por ejemplo en algunos proyectos realizados bajo el amparo y con el apoyo económico de grandes productoras de software como Microsoft, Autodesk, Adobe, Activision-Blizzard y que son publicadas bajo su marca.

8

Duración de la protección

En nuestro país el término de protección para las obras protegidas por el derecho de autor es de la vida del autor más 80 años después de la muerte de este, en aquellos casos en que la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra, estén en cabeza de una persona natural. Si el titular de derechos es una persona jurídica entonces el periodo de protección es de 50 años a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Para contabilizar el plazo de protección es necesario tener en cuenta, que este se contará a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra²⁷.

²⁴ Artículos 9 y 10 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

²⁵ Artículo 8 y artículo 18 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.

²⁶ Artículo 8 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 “Sobre Derecho de Autor”.

²⁷ Artículo 20 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.





Cuando se trate de obras de **dominio público** se hace referencia a creaciones que se caracterizan porque pueden ser utilizadas y explotadas por cualquier persona sin que requiera una autorización por parte de su titular, ya sea porque este lo ha expresado de tal forma o porque se terminó el periodo de protección otorgado por el derecho²⁸. La Ley establece las situaciones en las cuales las obras se encuentran en el dominio público, así²⁹:

- a. Obras cuyo período de protección esté agotado.
- b. Obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos.
- c. Obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos.
- d. Obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia.

Trámite del Registro de Soporte Lógico o software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor

El Registro Nacional de Derecho de Autor es un mecanismo mediante el cual los autores de obras literarias y artísticas pueden realizar el registro de sus creaciones. Es importante recalcar de nuevo que el registro no es constitutivo del derecho de autor, ya que este protege las obras desde el momento mismo de su creación. El registro es meramente declarativo y sirve principalmente como medio de prueba en caso de una eventual controversia jurídica y como medio de publicidad frente a terceros. Cabe destacar que el trámite del registro es totalmente gratuito y se realiza ante las oficinas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

9

- La solicitud de registro de obras puede ser presentada personalmente o enviada por correo a esta entidad, por el autor, titular o por un tercero apoderado, quien deberá presentar ante esta entidad, el documento mediante el cual se ha otorgado poder al solicitante.
- Se debe diligenciar el formato que para tal efecto ha sido diseñado la entidad; éste consta de la hoja denominada [Solicitud de Inscripción de Soporte Lógico o Software.doc](#), la cual puede ser obtenida en la página web de la institución o se puede solicitar personalmente en sus oficinas. Los datos allí requeridos deberán consignarse de idéntica manera en letra clara y legible, preferiblemente a máquina, sin enmiendas o correcciones, firmarse la hoja en original y remitirse junto con la copia de la obra y los demás documentos requeridos a la Oficina de Registro de esta entidad.
- Para el caso del software pueden registrarse cualquiera de estos tres elementos: la documentación completa, el código fuente o el manual de uso. El usuario deberá escoger cuál de estos elementos desea registrar o inclusive puede registrar los tres.
- Siempre se debe entregar una copia del material que se desea registrar, ya sea de manera material o electrónica. Para el caso de las copias electrónicas, éstas deben venir en un soporte óptico, CD o DVD y en alguno de los formatos genéricos que permitan ser leídos por los programas sobre los cuales la entidad tiene un licenciamiento jpg, .zip, .pdf, doc, .rtf, .odf, entre otras.

²⁸ ROBAYO, Elsa. MARTÍNEZ, Rodrigo. Lo que Usted debe Saber sobre el derecho de autor, Universidad de la Sabana. 2006.

²⁹ Artículo 187 de la Ley 23 del 28 de enero de 1982 "Sobre Derecho de Autor".





- En caso de adjuntarse copias físicas, siempre que estas superen las 5 hojas de extensión deben ser anilladas o empastadas.
- No se debe entregar tan sólo el material publicitario del software; es importante entregar la documentación que permita identificar de manera adecuada el software así como sus principales características.
- El trámite de registro tiene un término de duración de quince (15) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, y es totalmente gratuito.

Este trámite también puede realizarse de manera online por medio de la página web de la entidad, la cual cuenta con un instructivo acerca de los diferentes pasos a seguir. Este novedoso y práctico sistema de registro consta de dos pasos fundamentales, el primero de ellos, denominado **preinscripción**, se efectúa tan sólo una única vez. El segundo es propiamente el trámite de registro. Posteriormente, siempre ingresará con su nombre de usuario y contraseña, y tendrá a disposición todo el historial de actuaciones y sus certificados de inscripción³⁰. Es relevante destacar que la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia es pionera en el sistema de registro en línea y es uno de los más eficientes que existen en el mundo.

Diferencia entre la protección del derecho de autor y de la propiedad industrial en el software

10

El debate acerca de cómo debería ser la protección de los programas de ordenador ha sido amplio y se ha analizado desde diferentes aristas. Las discusiones surgieron en la década de los setentas y se multiplicaron a lo largo de los ochentas y noventas. Como se vio, la protección del software por medio del derecho de autor como una obra literaria ha sido reconocida y ratificada por distintos acuerdos y tratados internacionales así como por un gran número de legislaciones nacionales. Paralelamente, las discusiones sobre la posibilidad de protección del software a través de la propiedad industrial con su sistema de patentes han sobresalido por su variedad. Por ejemplo, en el año 2005 la Unión Europea intentó, aunque sin éxito, promulgar un proyecto de directiva comunitaria de programas de ordenador que buscaba regular este aspecto³¹.

En lo que respecta a legislaciones nacionales, el tema se ha manejado de diferentes maneras. Existen una gran cantidad de legislaciones que expresamente excluyen la posibilidad de patentabilidad del software como ocurre en Croacia, Malasia, Reino Unido, Colombia, entre otras. Igualmente, se encuentran las legislaciones donde, a pesar de que las leyes de patentes no excluyen al software directamente, este se encuentra indirectamente excluido por regulaciones internas y decisiones judiciales, como el caso de Canadá.

Una tercera categoría es aquella que no hace alusión en la normativa acerca de la exclusión del software en materia de patentabilidad, pues esta es determinada en la definición de una “invención” de acuerdo con los fallos emitidos por los máximos tribunales, apoyados en lo que define la legislación por dicho término. Una de los principales motivos para excluir al software del derecho de patentes es su estrecha similitud con los algoritmos matemáticos, no protegidos por la propiedad

³⁰ Para mayor información acerca del registro en línea ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor consultar: <http://200.91.225.125/registro-de-obras1>

³¹ Sherman Brad. Computer Programs as Excluded Patentable Subject Matter. WIPO. 2011. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_16/scp_16_ref_scp_15_3-annex2.pdf. Consultado el 18 de enero de 2015.





intelectual. Ejemplo de esta tipología constituyen los casos de Australia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y los Estados Unidos.

No obstante, este debate ha venido tomando un viraje distinto y gracias a ciertas decisiones judiciales se ha abierto la posibilidad de patentar el software en algunas circunstancias. El tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el famoso caso *Diamond vs. Diehr*³², determinó que el software no debía considerarse de manera aislada y autónoma, sino como una invención, que bajo este planteamiento, puede ser tomada como una innovación y, por ende, ser sujeto de patentabilidad³³. Igualmente, el Tribunal de justicia alemán en el caso *Sohei* de 1994 recalcó la protección del software a través del derecho de autor, pero dejó claro que en caso de que haga parte de algún elemento susceptible de ser patentado, debe ser protegido por la propiedad industrial en su sistema de patentes³⁴. Este caso concatena con el llevado por la Oficina Europea de Patentes decidido por su Junta Técnica de Apelaciones a raíz de una solicitud presentada por la compañía IBM sobre la patentabilidad de dos aplicaciones de la compañía que hacían parte de soportes susceptibles de ser leídos por el computador³⁵. La junta distinguió entre los simples programas de computador que no son patentables y los que tienen un carácter técnico no patentable. De esta forma, en Europa los programas de ordenador que están integrados o son parte fundamental de invenciones patentables permiten de manera indirecta replicar estos procedimientos con el software.

Por el contrario, el debate en los Estados Unidos ha ganado espacios de controversia en función del reciente caso *Bilski vs. Kappos*³⁶, en el que la Corte Suprema se apartó de la posición liberal de patentabilidad del software, expresada fundamentalmente en el caso del *State Street Bank*³⁷, y decidió alinearse a la posición de no patentabilidad del software, mayoritaria en el mundo. Como expresó el profesor Guadamuz, el Parlamento Europeo, al rechazar la aprobación del proyecto de Directiva Europea de Programas de Ordenador, los problemas planteados en torno a la patentabilidad del software no han sido resueltos y el debate real está por venir³⁸.

En Colombia la exclusión de patentabilidad del software está determinada en la Decisión Andina Número 486 de 2000, que regula lo referente a la propiedad industrial, y establece que no se consideran invenciones las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor, específicamente los programas de ordenador o soporte lógico como tales³⁹. Con esto, la prohibición de patentar el software en nuestro país esta promulgada de manera explícita. Esta restricción resulta coherente teniendo en cuenta que la patente protege por su naturaleza las ideas, mientras que en el derecho de autor estas no se protegen. Por último, debe considerarse que los acuerdos ADPIC, a los cuales el país está suscrito establecen que son patentables todas las invenciones que sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología⁴⁰, dejando abierto el debate sobre la patentabilidad del software.

³² Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos *Diamond vs. Diehr*, 450 U.S. 175, 185 (1981).

³³ AGUIRRE, David. El Posible Impacto de la Patentabilidad del Software en la Economía Colombiana. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Universidad de los Andes. Ed. 6. 2011.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Oficina Europea de Patentes. *IBM/Computer programs*, T935/97 [1999] EPOR 301 e *IBM/Computer programs*, T1173/97 [2000] EPOR 219.

³⁶ Corte Suprema de los Estados Unidos. *Bilski v Kappos* 561 US (2010).

³⁷ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F. 3d 1368, 1373 (CA Fed. 1998).

³⁸ GUADAMUZ, Andrés. The Software Patent Debate. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*. 2006.

³⁹ Literales c y e del artículo 15 de la Decisión Andina 486 de 2000 "Régimen común sobre propiedad intelectual".

⁴⁰ Artículo 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)





Bibliografía

- Adad Mamez, J. (25 de Agosto de 2011). *Lular*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es el Software de Dominio Público?: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Álvarez, M. Y. (1997). *El derecho de autor y el Software*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Arteaga Mejía, L. M., & Giovagnoli, H. (s.f.). *Proyecto Corporativo GNU*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es software libre?: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- Artigas Zubeldia, J. (20 de Octubre de 2010). *Software Libre*. Recuperado el 6 de Junio de 2012, de <http://softwarefreedom.wordpress.com/2010/10/20/licencias-agpl/>
- *Colombia Cumple*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.colombiacumple.com/riesgos.htm>
- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MINISTERIO DE JUSTICIA. *Obras creadas por los empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de sus obligaciones*. Bogotá.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (1995). *Eduteka*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de Limitaciones o Excepciones al derecho de autor: <http://www.eduteka.org/LimitesDerAutor.php3>
- Dirección Nacional de derecho de autor. (s.f.). *Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor*. Recuperado el 30 de Mayo de 2012, de <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- *Ejercicio y Tutela de los Derechos*. (s.f.). Recuperado el 05 de Junio de 2012, de http://www.robertexto.com/archivo6/ejer_tute_dchos.htm
- *El derecho de autor en la Era Digital*. (s.f.). Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de Qué es una licencia de Uso: http://www.ired.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html
- *Fundación Copyleft*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://fundacioncopyleft.org/es/9/que-es-copyleft>
- *Hispa Linux, Hacia La Sociedad del Conocimiento Libre*. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de <http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre>



- Intelectual, O. M. (s.f.). *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?* Recuperado el 05 de Junio de 2012, de OMPI: *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?*
- LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y Derechos conexos*. Argentina: UNESCO - CERLALC - ZAVALIA, 2006. 92-9057-047-4.
- Lular. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de *¿Qué es el software de dominio público?:* <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Navarro, V. (s.f.). *Lo hice y lo entendí*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/03/01/la-licencia-affero-agpl-y-su-relacion-con-la-gpl/>
- *Preguntas Linux*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://preguntaslinux.org/que-es-la-licencia-gpl-t-510.html>
- *Riesgos tecnológicos, económicos y legales del uso de software ilegal*. (8 de Abril de 2011). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.audienciaelectronica.net/2011/04/08/riesgos-tecnologicos-economicos-y-legales-del-uso-de-software-ilegal/>
- Ruiz, W. R. (2009). *La Propiedad Intelectual En La Era de Las Tecnologías*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Vega Jaramillo, A. (2010). *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Ventic's. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.ventics.com/licencia-bsd/>
- Guadamuz, A. (01 de 06 de 2008). *Patentabilidad del Software, Nuevas Cuestiones Jurídicas*. Recuperado el 06 de 06 de 2012, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html
- Peláez Luis, B. C. (02 de 07 de 2009). *El derecho de autor aplicado en Colombia a los programas de Ordenador (Software y las Bases de Datos)*. Recuperado el 07 de 06 de 2012
- Rodríguez, S. (2004). *La Era Digital, las excepciones y limitaciones al derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado.
- Sterling, J. (2009). *World Copyright Law*. Londres: Maxwell.
- Universidad de Jaén, V. d. (2010). *Universidad de Jaén, Vicerrectorado de Investigación*. Recuperado el 07 de 06 de 2012, de http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf





Portales electrónicos

- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/>
- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/ip.aspx>
- http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cadenasuper.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5240%3Aseguridad-y-administracion-de-software%26catid%3D71%3
- <http://www.colombiacumple.com/>
- <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- <http://www.fslcol.org/>
- <http://fidesol.org/>
- www.wipo.int





Los cursos fueron elaborados por:

- El centro de investigaciones para el desarrollo CID de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia:

Dirección

María Victoria Whittingham Munevar, Ph.D.

Elaboración de contenidos

Julio Cesar Padilla Herrera

Germán Dario Florez Acero

Diseño instruccional

Juan Camilo González Trujillo

Animación y programación

David Arturo Pacheco Puentes

15

- La Dirección Nacional de Derecho de Autor:



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Actualización y elaboración de contenidos

Carolina Romero Romero

Julián David Riatiga Ibáñez

Diseño y diagramación

Paula Alejandra López

